

<제9장 무효등 확인소송.제2절 무효등 확인소송의 요건>

I. 대상적격

- 무효등 확인소송의 대상적격은 행정소송법 제38조 제1항이 취소소송의 대상적격에 관한 규정인 제19조를 준용함으로써 정해진다. 즉, 무효등 확인소송의 대상은 행정청의 처분 또는 재결이다.

1. 처분

- 처분이란 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법 집행으로서의 공권력 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용을 말한다. 처분성이 인정되어야 무효등 확인소송의 대상이 될 수 있으며, 법규적 성격을 가지는 행정입법이나 단순한 사실행위 등은 원칙적으로 대상이 될 수 없다.

2. 재결

- 재결이란 행정심판의 심리 결과에 따라 행정심판위원회가 행하는 판단이다. 재결 자체에 고유하고 위법한 하자가 있는 경우에 한하여 무효확인을 구할 수 있다.

3. 처분의 존재

- 무효등 확인소송은 처분등의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 소송이므로, 그 확인을 구하는 대상인 처분등은 외형상 존재해야 한다. 다만, 부존재확인소송의 경우처럼 외형상 존재는 하나 법적으로 처분의 요건을 갖추지 못하여 처음부터 행정행위로서 성립하지 않은 경우도 대상이 될 수 있다.

II. 당사자적격

- 당사자적격은 무효등 확인소송을 제기할 수 있는 당사자(원고 및 피고)의 자격을 말하며, 권리보호의 필요성 및 참가인에 관한 요건도 포함된다.

1. 원고적격

- 원고적격은 행정소송법 제35조에 독자적으로 규정되어 있다. 원고적격은 처분등의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인을 구할 법률상 이익이 있는 자를 의미한다.

(1) 법률상 이익이 있는 자의 의미

- 법률상 이익이 있는 자는 취소소송의 원고적격(제12조)과 마찬가지로, 당해 처분의 근거 법규 및 관련 법규에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익을 침해당한 자를 의미한다. 단순히 사실상의 이익이나 간접적인 경제적 이해관계만으로는 부족하다.

(2) 제3자의 원고적격

- 처분의 직접 상대방이 아니더라도, 그 처분으로 인하여 법률상 보호되는 이익을 침해당하거나 침해될 우려가 있는 제3자에게도 무효등 확인을 구할 법률상 이익이 인정되는 경우 원고적격이 인정된다.

2. 피고적격

- 피고적격은 행정소송법 제38조 제1항에 의해 취소소송의 제13조가 준용된다.

(1) 원칙

- 소송의 대상인 처분등을 행한 행정청을 피고로 한다. 이때 행정청은 처분 당시의 행정청을 의미한다.

(2) 예외

- 처분등을 행한 행정청이 없게 된 때에는 그 처분등에 관한 사무가 귀속되는 국가 또는 공공단체를 피고로 한다.

3. 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)

- 권리보호의 필요성이란, 소송을 통해 원고가 주장하는 권리 또는 법률관계의 현존하는 불안정성을 제거하고 법적 안정을 기하는 데 소송 제기가 가장 유효하고 적절한 수단일 때 인정되는 요건이다. 무효등 확인소송에서는 이를 확인의 이익이라는 형태로 표현한다.

(1) 보충성 배제(판례)

- 민사소송상 확인의 소는 다른 직접적인 구제 수단(이행 소송)이 있는 경우 보충성이 요구된다. 그러나 무효등 확인소송에 대해서 대법원 전원합의체 판결은 무효확인소송의 보충성을 요구하지 않는다고 판시한다. 이는 무효확인판결의 실효성(기속력 등)이 취소판결에 준하여 인정되기 때문이며, 이행 소송 등 직접적인 구제 수단이 있는 경우에도 무효확인소송을 제기할 수 있어 국민의 구제 경로를 넓힌다.

(2) 확인의 이익

- 따라서 무효등 확인소송에서는 법률상 이익이 인정되면 특별한 사정이 없는 한 권리보호의 필요성(확인 이익)은 충족된 것으로 본다. 처분의 무효가 확인될 경우 그로 인해 법률관계의 불안정성이 해소되고 원고의 지위가 안정되는지 여부가 핵심이다.

4. 참가인(행소법 제38조 제1항)

- 행정소송법 제38조 제1항에 의해 취소소송의 참가인에 관한 규정인 제16조(제3자의 소송참가)와 제17조(행정청의 소송참가)가 준용된다.

(1) 제3자의 소송참가

- 소송의 결과에 따라 권리 또는 이익의 침해를 받을 제3자가 있을 때 법원은 당사자 또는 제3자의 신청 또는 직권으로 제3자를 소송에 참가시키거나 의견을 진술하게 할 수 있다. 무효확인소송의 판결은 제3자에게도 효력이 미치므로 제3자의 참가는 중요하다.

(2) 행정청의 소송참가

- 법원은 당사자의 신청 또는 직권으로 다른 행정청을 소송에 참가시키거나 소송에 참가하여 의견을 진술하게 할 수 있다.

III. 기타 요건

- 무효등 확인소송은 취소소송의 절차적 요건 중 일부를 배제한다.

1. 행정심판전치주의 및 제소기간(행소법 제38조 제1항)

(1) 행정심판전치주의

- 행정소송법 제38조 제1항은 취소소송의 전치주의에 관한 제18조를 준용하지 않는다. 따라서 무효등 확인소송에서는 행정심판전치주의가 적용되지 않는다. 무효인 처분은 공정력이 없어 처음부터 효력이 발생하지 않았으므로, 행정심판을 반드시 거치게 할 필요가 없기 때문이다.

(2) 제소기간

- 행정소송법 제38조 제1항은 취소소송의 제소기간에 관한 제20조를 준용하지 않는다. 처분이 무효인 경우에는 시간의 경과에 따라 그 효력이 회복되지 않으므로, 무효등 확인소송은 제소기간의 제한이 없어 언제든지 제기할 수 있다.

2. 재판관할(행소법 제38조 제1항, 제9조)

- 재판관할은 행정소송법 제38조 제1항에 의해 취소소송의 제9조(관할)가 준용된다.

(1) 원칙

- 피고의 소재지를 관할하는 행정법원에 제기한다.

(2) 예외

- 중앙행정기관 또는 그 장이 피고인 경우, 또는 국가의 사무를 위임 또는 위탁받은 공공단체 또는 그 장이 피고인 경우에는 대법원 소재지(서울)의 행정법원에도 제기할 수 있다. 부동산 또는 특정의 장소에 관련된 처분등에 대한 소송은 그 부동산 또는 장소의 소재지를 관할하는 행정법원에도 제기할 수 있다.

IV. 결론

- 무효등 확인소송의 요건은 행정소송의 특수성을 반영하여 취소소송의 요건과 차이를 보인다. 대상적격은 처분등으로 동일하나, 권리보호의 필요에서 직접적 구제 수단이 있어도 보충성이 요구되지 않는다는 판례의 태도가 확고하다. 특히 제소기간과 행정심판전치주의가 모두 배제되어 국민의 권리 구제에 있어 취소소송보다 광범위한 기능을 수행하는 것이 무효등 확인소송의 소송 요건상 중요한 특징이다.